

1502467-72.2021.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Antonio Canali Campanella

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/05/2022

... de fachada que, na verdade, era ponto de tráfico de entorpecentes), e os péssimos antecedentes criminais, circunstâncias concretas obstativas da aplicação da referida minorante. 8. Ordem denegada." (STF HC 111.666/MG Rel. Min. Luiz Fux j. 08.05.12 DJU 23.05.12).

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE PROVISÓRIA: ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

2ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Mauá - SP - cep 09371-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502467-72.2021.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502467-72.2021.8.26.0540

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO ALVES ROZA NETO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Antonio Canali Campanella

Vistos.

JOÃO ALVES ROZA NETO foi denunciado por incursão no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia que no dia 24 de outubro de 2021, por volta das 02 horas, na Rua Fernando Colombo, 118 - Jardim Salgueiro, nesta cidade e comarca de Mauá, o acusado traziam consigo e guardava, para entrega a consumo de terceiros, as substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica descritas no auto de exibição e apreensão (fls. 09-10) e laudos de constatação (fls. 26-37), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Recebida a denúncia, o réu foi citado (fl. 181) e apresentou resposta à acusação.

A testemunha arrolada pelas partes foi devidamente inquirida. Por fim, o réu foi interrogado.

Em memoriais, o Ministério Público requer a procedência da ação penal nos termos da denúncia, enquanto a Defesa, em preliminar, insiste no cabimento da proposta de acordo de não persecução penal. No mérito, busca a absolvição, ante a quebra da cadeia de custódia e a ilegalidade da atuação da guarda municipal ou, ao menos, a fixação da pena no patamar mínimo, reconhecendo-se a atenuante da confissão e o tráfico privilegiado, sob regime penitenciário inicial aberto, além da substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos.

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

Malgrado o esforço argumentativo do douto Defensor Público, a questão atinente ao acordo de não persecução penal já foi devidamente afastada no momento oportuno, destacando-se a falta de requisito objetivo (fls. 182-9).

No mérito, a acusação procede.

A materialidade está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 38-41), boletim de ocorrência (fls. 05-8), auto de exibição e apreensão (fls. 9-10), laudos de constatação (fls. 20-5), laudos de exame químico-toxicológico (fls. 100-5, 248-50 e 251-3), laudo pericial da bolsa apreendida (fls. 139-41) e prova oral colhida.

De início, frágil a alegação de que houve da quebra da cadeia de custódia em razão da diferença de peso no auto de exibição e apreensão e no laudo de constatação.

Ao contrário do alegado pela Defensoria Pública, os quantitativos não divergem, pois foram apreendidos pela Autoridade Policial e encaminhados para a perícia 33 invólucros de maconha e 52 invólucros de cocaína, conforme descrito no auto de exibição e apreensão (fls. 09-10) e nos laudos de constatação (fls. 20-5).

Note-se que, além da equivalência da quantidade de invólucros apreendidos – a mesma informada pelos guardas municipais (fls. 01-3) –, a numeração dos lacres indicada às fls. 15-6 corresponde àquela recebida pelo perito (fls. 20-5).

Não fosse o bastante, eventual divergência não prejudicou a comprovação da materialidade delitiva, já que os entorpecentes foram devidamente apreendidos, relacionados no auto de exibição e apreensão, lacrados e encaminhados à perícia.

Sobre o tema, manifestou-se o egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO – Ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 – Internação – Recurso recebido apenas no efeito devolutivo – Alegação de quebra da cadeia de custódia da prova – Inocorrência – Divergência entre o laudo de constatação e o laudo toxicológico definitivo, no que tange à numeração dos lacres dos entorpecentes, que se revelou como evidente erro material – Ínfima divergência de 0,17g entre o peso líquido das substâncias submetidas à análise que se justifica por diversos fatores, como, por exemplo, as distintas tecnologias empregadas nas balanças utilizadas, ou a menor rigorosidade do teste preliminar de constatação – Circunstâncias impassíveis de invalidar os laudos periciais – Quebra da cadeia de custódia não verificada [...] Apelação não provida. (TJSP; Apelação Cível 1501803-76.2019.8.26.0066; Relator (a): Renato Genzani Filho; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Barretos - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/07/2020; Data de Registro: 17/07/2020) g.n.

Apelação. Crime de tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal do acusado pelo crime de tráfico de drogas. 2. Não há dados a indicar quebra da cadeia de custódia. Na aferição da higidez da prova sob a óptica da cadeia de custódia, importa atentar, mais do que o cumprimento estrito das formalidades em si, para a finalidade do instituto. Neste passo e sempre tendo por parâmetro o princípio da instrumentalidade das formas - não se declara a invalidade sem comprovação de prejuízo, ainda que se cuide de nulidade absoluta, tal como tem assentado o Supremo Tribunal Federal (HC nº 81.510, rel. Min. Sepúlveda Pertence, HC nº 85.155-0, rel. Min. Ellen Gracie; RHC nº 123.890, rel. Min. Cármen Lúcia; RHC nº 122.467, rel. Min. Ricardo Lewandowski; ARE nº 868.516 AgR, rel. Min. Roberto Barroso; AP nº 481 EIED, rel. Min. Dias Toffoli, entre outros), impende aferir se, no caso concreto, as providências tomadas (ou não tomadas) deixam alguma dúvida sobre a identidade entre o material apreendido e o periciado, bem como no tocante à conservação do material apreendido para fins da perícia. Somente se deve declarar a invalidade se existir fundada suspeita de que o procedimento colocou em risco a credibilidade da prova. 3. Sanção que não comporta alteração. 4. Circunstâncias a impor o regime inicial fechado para a pena privativa de liberdade, ainda que tendo em conta o tempo de prisão provisória. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1501092-36.2020.8.26.0228; Relator (a): Laerte Marrone; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 11ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/12/2020; Data de Registro: 13/12/2020). g.n.

Além disso, não há obrigatoriedade de fotografar os entorpecentes. Nessa linha, a jurisprudência:

"As alterações trazidas pelo artigo 158-A, do Código de Processo Penal, sugere entre outras opções para a identificação e preservação da prova a fotografia, mas não impõe obrigatoriedade, de modo que a ausência de fotografia da droga apreendida no momento da ação policial não infirma a cadeia de custódia. Assim, o auto de exibição e apreensão é suficiente para identificar a droga apreendida, a qual recebeu lacre numerado e permitiu o sequenciamento do auto de custódia e do exame químico toxicológico, sem contar que os policiais militares possuem, como funcionários públicos, fé pública, havendo presunção de veracidade dos seus atos passíveis de questionamento, mas sob a apresentação de provas" (TJSP, AP nº 1502830-74.2020.8.26.0320, Rel. Des. RACHID VAZ DE ALMEIDA, j. 25.05.21) g.n.

Adiante.

Comprovou-se a autoria.

O réu foi devidamente interrogado, em solo policial e sob o contraditório (fl. 04 e mídia digital).

Os guardas civis municipais, na fase administrativa, historiaram que (sic) "realizavam patrulhamento pelos Bairros Jd Flórida e Parque das Américas, em razão de reclamações feitas por inúmeros moradores, sobre a colocação de obstáculos nas vias, por pessoas possivelmente ligadas ao tráfico de drogas, dificultando a circulação de pessoas e veículos na comunidade; quando transitávamos pela Rua FERNANDO COLOMBO, 118 - JARDIM SALGUEIRO, suspeitamos das atitudes de um indivíduo que vimos carregando uma mochila e que passou a se mostrar bastante nervoso ao ver nossa viatura, razão pela qual o abordamos e submetemos ele à busca pessoal; nessa busca, nada de ilícito encontramos junto do corpo ou sob as vestes do suspeito, então identificado como JOÃO ALVES ROZA NETO; mas quando olhamos o interior daquela mochila, descobrimos que nela havia uma bolsa menor e que dentro dela, o abordado guardava e transportava inúmeras porções e frascos que aparentavam conter drogas, no caso, 33 (trinta e três) invólucros de maconha, 52 (cinquenta e dois) invólucros cocaína e 4 (quatro) frascos envazando um líquido, provavelmente lança-perfume, além da quantia de R\$68,00 (sessenta e oito reais) em espécie; questionamos JOÃO

ALVES sobre aquele material e ele confirmou ser mesmo drogas, revelando que começou a traficar no local para pagar dívidas que teria com outros traficantes e que, mesmo depois de ter pago tal dívida, estaria sendo obrigado a continuar com o comércio ilícito de drogas, razão pela qual lhe demos voz de prisão em flagrante e, junto daquelas porções e frascos apreendidos o apresentaram nesta Delegacia, para providências de polícia judiciária cabíveis; munidos de requisição ao IML, conduzimos o capturado até o IML; lá, quando ele estava sendo examinado pelo sr. perito, caiu de suas vestes mais 14 (quatorze) invólucros plásticos, apresentando conter resquícios de drogas, os quais foram acondicionados num saco plástico, fechado com o lacre nº 653430, os quais apresentados junto com o capturado quando do seu retorno à Delegacia" (fls. 01-3).

Em juízo, o guarda municipal Elvis reiterou integralmente a dinâmica do ocorrido e confirmou ter apreendido as drogas com o réu, que estava em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes. Segundo a testemunha, ao visualizar a equipe, o réu apresentou muito nervosismo e tentou fugir, o que motivou a abordagem. Informalmente, o suspeito admitiu a prática delitiva (mídia digital).

A prova por meio de depoimento de guardas municipais não é desvaliosa, quanto ao actum a que corresponda, pela só condição profissional das testemunhas. Ao revés, estar-se-ia diante de uma acepção processual de pessoas com apoio em predicado genérico. A jurisprudência dos Tribunais é firme no sentido de que não é causa simpliciter de menor credibilidade a circunstância de uma testemunha ser policial, o que também se aplica aos guardas civis municipais. Em caso análogo:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (STF HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07).

Registre-se que a abordagem realizada pelos guardas municipais, no caso concreto, encontra respaldo no art. 5º da Lei nº 13.022/2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais), o qual regulamentou o § 8º do art. 144 da Constituição Federal e permite o patrulhamento preventivo a fim de "colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social" (inciso IV) e "encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário" (inciso XIV).

No caso dos autos, durante patrulhamento pelo local, visando a proteção da população local, os agentes municipais depararam-se com a situação flagrancial.

Além disso, o crime de tráfico de drogas é permanente, de forma que, enquanto atuava para o narcotráfico e trazia consigo os entorpecentes, o investigado encontrava-se em flagrante delito.

Destaca-se, também, a ausência de qualquer irregularidade na prisão em flagrante efetuada por guardas municipais, diante da autorização prevista no art. 301 do Código de Processo Penal.

Sobre o tema, posicionou-se o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Revisão Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Ajuizamento de ação

revisional. Alegada obtenção de provas por meios ilícitos, posto colhidas por guardas municipais. Impossibilidade. Nulidade não verificada. Pedido de absolvição. Mera intenção de reexame dos fatos. Conjunto fático exaustivamente enfrentando. Inexistência de fatos supervenientes a justificar reanálise do conjunto probatório. Ação revisional que não se perfaz em uma terceira apelação. Mérito mantido. Improcedência. [...] Não se vislumbra, in casu, a alegada obtenção das provas por meios ilícitos, porquanto não só os guardas municipais podem efetuar a prisão em flagrante, como qualquer um do povo pode fazê-lo. É o teor do artigo 301, do Código de Processo Penal. Ademais, os guardas municipais responsáveis pelo flagrante delito encontravam-se atuantes nos estritos termos dispostos pela Lei 13.022/2014 que regulamentou a competência atribuída à Corporação pelo artigo 144, § 8º, da Constituição Federal. Com a edição de referida Lei, a guarda municipal, no seu território, pode exercer a polícia ostensiva e auxiliar as forças estaduais e federais na segurança pública. Particularmente, no âmbito do flagrante, destaca-se o artigo 5º, inciso XIV, da Lei 13.022/2014. Embora o preceituado neste artigo ultrapasse os limites previstos no artigo 144, § 8º, da CF, entendemos constitucional a previsão. Afinal, tudo o que se relaciona com o município não deixa de ter relação com a tutela dos bens, serviços e instalações do Município onde reside. Ademais, deixou-se cláusula aberta ao final do parágrafo, "conforme dispuser a lei". Diante disso, a guarda municipal tem hoje, dentro dos limites municipais, o mesmo poder da Polícia Militar. [...]" (TJ/SP, Revisão Criminal nº 2017191-29.2020.8.26.0000, 8º Grupo de Direito Criminal, Rel. Des. Guilherme De Souza Nucci, Data do julgamento: 13/07/2020, Data de publicação: 13/07/2020 - grifo nosso).

APELAÇÃO TRÁFICO DE DROGAS Preliminar de nulidade Alegação de incompetência dos guardas municipais para efetuar a prisão em flagrante Descabimento Réu que estava em atitude suspeita Situação de flagrância Legalidade da prisão efetuada por guardas municipais (art. 301 do CPP) Preliminar rejeitada MÉRITO Pleito de desclassificação Impossibilidade Materialidade, autoria e destinação das drogas evidenciadas nos autos Desnecessidade de se surpreender o agente em atos de comercialização Crime de conteúdo variado Condenação mantida PENA Quantidade e variedade de drogas a inviabilizar a aplicação, na fração máxima, do art. 33, §4o, da Lei 11.343/06 Abrandamento do regime prisional Desacolhimento, por maioria Preliminar rejeitada e recurso desprovido. (TJ/SP, Apl. Criminal nº 0000508-07.2016.8.26.0544, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 27/06/2017, Data de publicação: 03/07/2017).

No mesmo sentido, há julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:

"Sem razão a defesa também no ponto em que afirma haverem as guardas municipais exorbitado os limites do patrulhamento preventivo, ao agirem como polícia ostensiva. No caso, não se está a reconhecer o policiamento ostensivo das guardas municipais, mas sim a atribuição de funções essenciais à proteção da população local, bem como de bens, serviços e instalações. É possível que, durante o patrulhamento preventivo, destinado à salvaguarda dos sobreditos bens jurídicos, o agente municipal se depare com situação de flagrante delito ou, ainda, que, diante de notitia criminis, envolvendo qualquer dos bens jurídicos mencionados, proceda à atividade de vigilância no local indicado para se certificar de sua veracidade, hipóteses nas quais, de nenhum modo, estaria desautorizado a agir. A situação de flagrância delitiva legitima a atuação de "qualquer pessoa do povo" a proceder à prisão, oportunidade em que é perfeitamente possível a realização da abordagem do suspeito, não sendo diferente em relação àqueles agentes que, ao realizarem seu mister de zelar pelo patrimônio público, muitas vezes se deparam com infrações penais, sendo-lhes lícito atuar em tais ocasiões. Além disso, a Lei n. 13.022/2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais) prevê, expressamente, como princípio mínimo de atuação das guardas municipais, o patrulhamento preventivo (art. 3º, III) e, não obstante dispositivos da referida legislação sejam objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.156, certo é que, até o momento, não houve nenhuma

decisão por parte da Corte Suprema, de maneira que a lei em questão continua em pleno vigor no ordenamento jurídico pátrio. Finalmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, em reiterados julgados, já manifestou entendimento de que o art. 144 da Constituição Federal não estabelece o monopólio da função de investigação criminal à polícia. Destarte, a sua interpretação, vista em conjunto com o art. 4º, parágrafo único, do Código de Processo Penal, legitima a atuação investigativa por outras autoridades (v. g., AP n. 611/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, 1ª T., DJe 10/12/2014). Válida, portanto, foi a atuação das guardas municipais e, por conseguinte, a apreensão de substâncias entorpecentes por elas levada a efeito após a realização de revista pessoal no acusado." (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.715.660 - SP (2017/0324006-0), Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Publicado em 17/02/2020 - grifo nosso).

"[...] Pois bem, do excerto transcrito verifica-se que o acórdão impugnado não destoaria da jurisprudência desta Corte, que entende que a busca e apreensão de drogas efetuada por guardas municipais não padece da eiva suscitada, embora a Guarda Municipal não possua a atribuição de polícia ostensiva, mas apenas aquelas previstas no art. 144, § 8º. da Constituição da República, sendo o delito de natureza permanente, pode ela efetuar a prisão em flagrante e a apreensão de objetos do crime que se encontrem na posse do agente infrator, nos termos do art. 301 do CPP . Precedente. (AgRg no AREsp n. 1.565.524/MS, Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), Quinta Turma, DJe 12/12/2019). Ainda nesse sentido: AgInt no AREsp n. 950.569/MS, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 21/02/2017; e HC n. 525.772/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 24/10/2019. [...]." (STJ, HC 557934, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Publicado em 17/04/2020).

Descabida a alegação da Defesa quanto à ilegalidade na busca pessoal, uma vez que os guardas municipais que realizaram a abordagem afirmaram que, durante patrulhamento realizado em local conhecido pela prática de tráfico de drogas, visualizaram o réu com uma mochila apresentando nervosismo, bem como tentou empreender fuga ao visualizar a equipe, de forma que demonstradas as fundadas razões para a busca pessoal.

No mais, a quantidade de droga encontrada e as demais circunstâncias da apreensão, tais como a variedade e a forma em que era transportada, o local da abordagem, ponto de tráfico, além do dinheiro apreendido, trazem elementos suficientes de que o réu tinha a droga para entrega a terceiros.

Dessa forma, entendo que o delito de tráfico de drogas está fartamente comprovado.

Passo à fixação da pena.

Atendendo aos ditames do art. 42 da Lei 11.343/06 e do art. 59 do Código Penal, fixa-se a pena base no patamar mínimo, qual seja, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda etapa, justifica-se a não incidência da atenuante da confissão, não espontânea, em razão de sua inutilidade para o desate da ação penal. Isso porque a confissão de quem foi preso em flagrante, em ponto de tráfico e em poder dos entorpecentes, não tem o intuito de colaborar para a elucidação dos fatos. Não fosse suficiente, o presente decisor sequer referiu-se ao interrogatório do réu, portanto, sem infringência à Súmula 545 do STJ.

Sobre a necessidade da espontaneidade da confissão, decota-se trecho do voto do v. acórdão proferido pelo eminente Desembargador Ricardo Dip, no julgamento da Apelação Ordinária 1.390.581-8:

"Em acréscimo, confissão do acusado, houve. Espontânea, contudo, não; a que houve, tem caráter de provocada.

É válida –recruto de votos precedentes–, é válida, repito, ainda após a controvertida Reforma do Código Penal em 1984, esta lição de Roberto Lyra:

'A espontaneidade da confissão não diz respeito, é claro, à sua prestação, em que seria redundante a referência...' (Comentários ao Código Penal, ed. Forense, Rio de Janeiro, 1958, vol. 2, n. 64).

Não fosse assim, sobejaria a lei, porque, como disse Fragoso, 'se o agente confessa sob pressão policial, fato, aliás, comum, nenhuma atenuante será aplicável' (Lições de Direito Penal, ed. Forense, Rio de Janeiro, 1994, Parte Geral, n. 345).

Na mesma linha, disse Mirabete: 'Não basta a confissão para a configuração da atenuante; é necessário que o agente, arrependido, procure a autoridade para a confissão, já que a lei não fala em ato voluntário, mas em confissão espontânea' (Manual de Direito Penal, ed. Atlas, São Paulo, 1997, vol. 1, 7.5.6).

Diz José Antonio Paganella Boschi, comentando o disposto na alínea d, inc. III, art. 65, CP: 'Foge ao sentido do texto, portanto, reconhecer a atenuante quando o agente é preso em flagrante e não tem como negar as evidências em torno da autoria ou imputar a responsabilidade pelo fato a terceiro. Inconfundíveis confissão espontânea e confissão voluntária' (Das Penas e Seus Critérios de Aplicação, ed. Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2002, p. 273).

A espontaneidade da confissão –prevista em lei como qualificação necessária do ato confessorio para atuar como causa de atenuação penal– distingue-se da mera voluntariedade da confissão. Não se trata aí do espontâneo como o que procede de um princípio interno juxta naturam agentis, sine deliberatione (Marcelino Zalba), mas do que (disse Cathrein) procedit a princípio interno –ou seja, sem provocação exterior." (TACRIM-SP –11a Câmara)

Manifestou-se, também, o Supremo Tribunal Federal quanto à incompatibilidade da atenuante da confissão espontânea com a situação de flagrância:

"CONFISSÃO ESPONTÂNEA ATENUANTE. Em se tratando de situação concreta em que ocorrida a prisão em flagrante, em razão do transporte de vultuosa quantidade de droga, descabe cogitar da atenuante da confissão espontânea, no que esta última tem como objetivo colaborar com o Judiciário na elucidação da verdade real". (HC 101.861/MS, rel. Min. Marco Aurélio, 1ª T., j. em 13.04.2011)

No mesmo julgamento, manifestou-se o Min. Luiz Fux: "Eu também entendo que confissão espontânea e flagrante é contradictio in terminis, não dá para conviver; ou confessa voluntariamente ou é preso em flagrante. Não fez favor nenhum à Justiça".

Na mesma direção, precedentes do e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Apelação- Tráfico de entorpecentes - Recurso da defesa- Pedido para que o réu possa recorrer em liberdade prejudicado pelo presente julgamento. Condenação mantida. Apreensão de 20 porções de maconha e 61 porções de cocaína- Conjunto probatório seguro e coeso. Dosimetria fixada com rigor- Pena fixada no mínimo legal - Pedido de compensação entre confissão e reincidência- Inadmissibilidade- Confissão que sequer foi considerada na formação do convencimento do julgador- Redutor do art. 41 da Lei de Drogas- Não cabimento- Delação após prisão em flagrante com tóxico- Ausência de colaboração efetiva. Regime inicial Fechado obrigatório para réu reincidente condenado a corporal superior a quatro anos- Sentença mantida. Recurso improvido." (TJSP, AP 1501244-55.2019.8.26.0540, Rel. Des. José Vítor Teixeira de Freitas, j. 29.06.20).g.n.

"[...] Não assiste razão ao apelante quando pleiteia o benefício da atenuante da confissão espontânea, previsto no artigo 65, III, "d", do Código Penal, pois, no caso de que se trata, a confissão, além de absolutamente prescindível para o desate

condenatório, em razão da solidez da prova incriminadora produzida sob o crivo do contraditório, bem revelando hábil manejo de autodefesa para tentada incidência da atenuante genérica do art. 65, III, "d", do Código Penal. Assim, por não espontânea e desacompanhada de arrependimento, não permitiria a diminuição da pena pela atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal. Nesse sentido, "espontânea é aquela confissão em que o agente, independentemente do concurso da autoridade, busca esta para admitir o delito" (Apelação nº 0001496-21.2009.8.26.0270. Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Rel. Exmo. Des. LUIS SOARES DE MELLO, j. em 26.6.2012). No mesmo sentido: veneranda decisão da Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na Apelação nº 0052302-70.2011.8.26.0050. Rel. Exmo. Des. LUIS SOARES DE MELLO, j. em 16.4.2013). Da mesma forma: STF HC. nº 101.861/MS, Rel. Exmo. Min. MARCO AURÉLIO, j. em 13.4.2011). No mesmo sentido: PROVA - CONFISSÃO ESPONTÂNEA E VOLUNTÁRIA - DISTINÇÃO. "Não se pode confundir a confissão espontânea com a confissão voluntária do réu surpreendido em plena execução do delito. Esta é uma declaração movida por uma circunstância de evidência dos fatos, aquela pela mera intenção de declarar a verdade". (Apelação nº 566.425/1, Julgado em 01/02/1990, Col. 1ª Câmara, Rel.: ALBERTO MARINO. RJDTACRIM 5/169)" (TJSP; Apelação Criminal 1501404-12.2021.8.26.0540; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/02/2022; Data de Registro: 22/02/2022). g.n.

"(...) Afasta-se o pleito de reconhecimento da atenuante da confissão. Isso porque Paulo foi preso em flagrante vendendo drogas a um adolescente e outro indivíduo, de modo que sua confissão não foi utilizada para formação da convicção. O flagrante e os depoimentos das testemunhas são suficientes para sustentar sobremaneira o édito condenatório." (TJSP, 4ª Câmara Criminal, Apelação nº 1500902-44.2018.8.26.0616,, rel. Des. Roberto Porto, j. 18.6.2020, V.U.).g.n.

"(...) Ademais, sobreleva registrar que a referida confissão não foi utilizada pelo magistrado sentenciante como elemento de convicção, não incidindo, assim, na hipótese, a Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça. (...) Veja que, para o reconhecimento da finalidade mercantil da droga apreendida com o acusado, o douto juiz não utiliza de sua confissão a esse respeito, mas sim dos demais elementos de convicção colhidos." (TJSP, 4ª Câmara Criminal, Apelação nº 1500646-88.2020.8.26.0630, rel. Des. Camilo Léllis, j. 22.3.2022, V.U.). g.n.

Apelação criminal - Tráfico de drogas - [...] Dosimetria - pena-base justificadamente fixada acima do mínimo legal. Inteligência do art. 42 da Lei de Drogas. Na segunda fase, exasperação decorrente da reincidência. Confissão que não foi considerada na formação do convencimento do julgador. [...] Preliminar rejeitada. Recurso defensivo improvido. "[...] verificando-se que neste caso, não houve qualquer menção ao teor do interrogatório do acusado para a formação do convencimento do douto Julgador para o deslinde desta ação penal, não há como se acolher o pleito de consideração da referida atenuante de pena, nos termos dos abalizados entendimentos jurisprudenciais referidos." (TJSP; Apelação Criminal 1500255-44.2022.8.26.0540; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/05/2022; Data de Registro: 08/05/2022).

"APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo duplamente majorado - Incidência da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo comprovada pela prova pessoal - Desnecessidade de apreensão e perícia da arma usada no roubo. (...) Impossibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, porquanto não utilizada para fundamentar a condenação - Aumento único no concurso de causas de aumento de pena contemplado no parágrafo único do artigo 68 do Estatuto Penal que não constitui direito subjetivo, tratando-se de faculdade judicial, que, porém, requer justificativa sobre a fração imposta, como no caso penas e regime prisional fechados mantidos. RECURSO DEFENSIVO

DESPROVIDO." (TJSP, Apelação Criminal nº 1500106-76.2021.8.26.0348, Rel. Des. Adilson Paukoski Simoni, j. 12.04.22).

Não bastasse, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu, recentemente:

"Agravos regimental no habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Matéria não analisada na apelação. Óbice à inovação em sede de embargos de declaração. Constrangimento ilegal inexistente, Atenuante da confissão espontânea. Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça STJ. Édito condenatório apoiado em outros elementos. Não incidência. Precedentes. Agravo regimental desprovido. 1. [...] 2. Ainda que controverso o fato de que o paciente assumiu a autoria do delito, esse dado não foi utilizado para a formação do convencimento do julgador. Conforme se verifica, a condenação está amparada no testemunho da vítima e dos policiais condutores da prisão, sendo portanto, inviável a redução da reprimenda. Precedentes, 3. Agravo regimental desprovido (STJ AgRg no HC 648.216/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08.06.2021, DJe, 15.06.2021).g.n

"A Súmula 545/STJ prevê que a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação. Evidenciado que a confissão informal do réu somente foi explicitada na transcrição dos depoimentos dos policiais condutores, não tendo, todavia, sido utilizada em momento algum para embasar a condenação, sequer citada pelo magistrado sentenciante, deve ser afastada a possibilidade de reconhecimento da atenuante do art. 65, III, 'd', do Código Penal" (AgRg no AREsp 1599610/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020).

Ainda assim, a pena não poderia ficar aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Registre-se que não deve incidir, no caso concreto, a causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Restou demonstrado que o réu trazia consigo relevante quantidade de drogas, de diversas espécies, dentre elas cocaína, de alto poder vulnerante; em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes. Não bastasse, há notícia de que João já praticou o tráfico outra vez, uma semana antes da abordagem (mídia digital - interrogatório), bem como não comprovou o exercício de atividade lícita, a indicar um acentuado envolvimento no comércio de entorpecentes, ou seja, a não ocasionalidade da conduta. Nessa direção:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, I, DA LEI 11.343/2006). CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. AFASTAMENTO PELO JUÍZO SENTENCIANTE E PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. ANÁLISE DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA OU DE SER INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADES NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM DENEGADA. 1. A causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da lei 11.343/06 está condicionada ao preenchimento, cumulativo, dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes e agente que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. [...] 3. A conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza do entorpecente, os apetrechos utilizados e as circunstâncias em que a droga foi apreendida podem constituir o amparo probatório para o magistrado reconhecer a

dedicação do réu à atividade criminosa. Precedentes: RHC 94.806/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16/04/2010; HC 116.541/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 6/6/2013; HC 98.366/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 5/2/2010. [...] (STF HC 121.057/SP Rel. Min. Luiz Fux j. 25.02.14 DJU 18.03.14).

"HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE DO §4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA, MAUS ANTECEDENTES E DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. PRESUNÇÃO HOMINIS. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS. APTIDÃO PARA LASTREAR DECRETO CONDENATÓRIO. SISTEMA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. DESCABIMENTO NA VIA ELEITA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA APTA A AFASTAR A MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06, ANTE A DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ORDEM DENEGADA. 1. O §4º do artigo 33 da Lei de Entorpecentes dispõe a respeito da causa de diminuição da pena nas frações de 1/6 a 2/3 e arrola os requisitos necessários para tanto: primariedade, bons antecedentes, não dedicação à atividades criminosas e não à organização criminosa. 2. Consectariamente, ainda que se tratasse de presunção de que o paciente é dedicado à atividade criminosa, esse elemento probatório seria passível de ser utilizado mercê de, como visto, haver elementos fáticos conducentes a conclusão de que o paciente era dado à atividade delituosa. 3. O princípio processual penal do favor rei não ilide a possibilidade de utilização de presunções 'hominis' ou 'facti', pelo juiz, para decidir sobre a procedência do 'ius puniendi', máxime porque o Código de Processo Penal prevê expressamente a prova indiciária, definindo-a no art. 239 como 'a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias'. Doutrina (LEONE, Giovanni. Trattato di Diritto Processuale Penale. v. II. Napoli: Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, 1961. p. 161-162). Precedente (HC 96062, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009, DJe-213 DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 13-11-2009 EMENT VOL-02382-02 PP-00336). 4. Deveras, o julgador pode, mediante um fato devidamente provado que não constitui elemento do tipo penal, utilizando raciocínio engendrado com supedâneo nas suas experiências empíricas, concluir pela ocorrência de circunstância relevante para a qualificação penal da conduta. 5. A criminalidade dedicada ao tráfico de drogas organiza-se em sistema altamente complexo, motivo pelo qual a exigência de prova direta da dedicação a esse tipo de atividade, além de violar o sistema do livre convencimento motivado previsto no art. 155 do CPP e no art. 93, IX, da Carta Magna, praticamente impossibilita a efetividade da repressão a essa espécie delitiva. 6. O juízo de origem procedeu a atividade intelectual irrepreensível, porquanto a apreensão de grande quantidade de droga é fato que permite concluir, mediante raciocínio dedutivo, pela dedicação do agente a atividades delitivas, sendo certo que, além disso, outras circunstâncias motivaram o afastamento da minorante. 7. In casu, o Juízo de origem ponderou a quantidade e a variedade das drogas apreendidas (1,82g de cocaína pura, 8,35g de crack e 20,18g de maconha), destacando a forma como estavam acondicionadas, o local em que o paciente foi preso em flagrante (bar de fachada que, na verdade, era ponto de tráfico de entorpecentes), e os péssimos antecedentes criminais, circunstâncias concretas obstativas da aplicação da referida minorante. 8. Ordem denegada." (STF HC 111.666/MG Rel. Min. Luiz Fux j. 08.05.12 DJU 23.05.12).

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE PROVISÓRIA: INADMISSIBILIDADE. DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO VOLTADA PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA: CIRCUNSTÂNCIAS SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06 E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA: IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. [...] 6. Os fatos que deram ensejo à não aplicação da causa de diminuição de pena prevista na Lei de Tóxicos são hígidos e suficientes para atestar a dedicação do Paciente às atividades criminosas. 7. A conduta social

do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas. [...] (STF HC 109.236/SP Rel. Min. Cármen Lúcia j. 13.12.11 DJU 14.23.12).

EMBARGOS INFRINGENTES. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRIVILÉGIO, REGIME DIVERSO DO FECHADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. Acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso defensivo para fixar a pena-base em seu patamar mínimo e, por maioria de votos, deu provimento ao recurso ministerial, para afastar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, majorando as penas do embargante para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, e fixar o regime inicial fechado, vencido em parte o E. Des. Ricardo Sale Júnior, que negava provimento ao recurso acusatório, mantendo o redutor e regime semiaberto, aplicados em primeiro grau. Maioria que considera imperativo o afastamento do redutor, pelas circunstâncias em que o crime de tráfico ilícito de entorpecentes foi praticado – quantidade e variedade considerável de entorpecentes (16 porções de cocaína, na forma de crack, com massa de 49,7 gramas; e 02 porções de maconha, pesando 41,7 gramas pesos líquidos, cf. laudos de fls. 16/17 ou 53/54 e 89/91), além de dinheiro – circunstâncias concretas que indicam que o apelado já gozava da confiança na cadeia da traficância para, com habitualidade, executar este tipo de tarefa. Regime inicial de cumprimento de pena fechado imperativo, ante a gravidade concreta do delito praticado, com vistas principalmente à repressão e à prevenção delitiva e resguardo da tutela social, ao menos no início do cumprimento da pena privativa de liberdade, tal como decidiu a douta Turma Julgadora, por maioria de votos. Embargos infringentes rejeitados. (TJSP; Embargos Infringentes e de Nulidade 0000079-92.2017.8.26.0580; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Assis - 2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; Data do Julgamento: 19/05/2021; Data de Registro: 19/05/2021 – grifo nosso).

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstradas – Confissão do acusado – Falas dos policiais firmes e coerentes – Depoimentos que se revestem de fé-pública, corroborados pelo conjunto probatório – Ausência de provas de que teriam intuito de prejudicar o réu – Traficância comprovada – Condenação era de rigor – Causa de aumento comprovada – Penas bem dosadas – Privilégio do art. 33, § 4º, da LD – Não cabimento – Regime inicial fechado mantido – Substituição da pena corporal por restritivas de direitos – Impossibilidade – Sentença mantida – Recurso defensivo desprovido. [...] No presente caso, o réu possuía quase 100 porções de drogas variadas, dentre eles, cocaína e crack, entorpecentes de elevado potencial lesivo, demonstrando seu envolvimento na atividade criminosa. Ademais, não comprovou ocupação lícita, e confirmou que já atuava na venda ilegal havia um mês. Portanto, à luz das peculiaridades do caso em tela, em que pese a primariedade do réu, é inegável que as circunstâncias concretas do delito praticado impedem a aplicação do §4º, do artigo 33, da lei 11.343/06. Frise-se que mencionado parágrafo 4º emprega o termo “poderão”, o que seguramente indica não ser obrigatória a redução. [...] (TJSP; Apelação Criminal 1501589-14.2020.8.26.0628; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Embu das Artes - 2ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 16/05/2022; Data de Registro: 16/05/2022 – grifo nosso).

Define-se, assim, a condenação em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

O valor de cada dia-multa foi estabelecido no mínimo ante a ausência de dados nos autos quanto à situação econômica do réu.

Registre-se que o plenário do Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o art. 44 da Lei 11.343/06, nas partes em que se vedava a concessão de liberdade provisória (HC n. 104.339, rel. Min. Gilmar Mendes) e a conversão da pena privativa

de liberdade em restritiva de direitos (HC n. 97,256, rel. Min. Ayres Britto), bem como do parágrafo 1º do art. 2º da Lei n. 8072/90, que impunha o regime inicial fechado (HC n 111.849, rel. Min. Dias Toffoli).

Todavia, a gravidade in concreto do delito, considerando a quantidade, assim como o alto potencial lesivo da cocaína para saúde pública, indica um grau acentuado de culpabilidade, de forma que o regime inicial fechado mostra-se necessário para o cumprimento da pena privativa de liberdade. Assim já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE COMO FUNDAMENTO PARA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL E PARA A NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ORDEM DENEGADA. Possibilidade de fixar regime inicial fechado e de afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido. Precedentes.Ordem denegada.” (STF – HC 119.515/AC – Rel. Min. Cármen Lúcia – j. 03.12. – DJU 10.12.13)

Sobre o potencial lesivo da quantidade de cocaína apreendida:

“A cocaína pode produzir uma intoxicação grave e por vezes inesperadamente com pequenas doses. A dose letal pode estar entre 0,8 a 1,2 g para um homem de 70 kg. No entanto, fumadores de base livre reportam uso de quantidades que excedem a 1 g. Em contrapartida, há casos em que se pode ocorrer o óbito com uma dose extremamente baixa de 20 mg. Isto pode ser explicado pela ocorrência da tolerância reversa que se caracteriza ou pelo aumento da susceptibilidade ao aparecimento de convulsões em doses consideradas recreacionais ou por uma excitação aumentada obtida em doses menores em usuários crônicos, fato que pode ser explicado pela diminuição da biossíntese dos neurotransmissores, o que leva a uma potencialização dos efeitos excitatórios.” (Passagli, Marcos; Toxicologia Forense – Teoria e Prática, 5ª ed., Millennium: Campinas, 2018 – pg. 180-1).

Pelo mesmo motivo, não é hipótese de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, insuficiente para prevenção e reprovação da conduta.

Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na ação penal para CONDENAR o réu JOÃO ALVES ROZA NETO, qualificado nos autos, a cumprir pena de 05 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e a pagar 500 dias-multa, no patamar mínimo, por incursão no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Faculta-se ao réu o apelo em liberdade.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Diante da concordância ministerial (fl. 90), com o trânsito em julgado, oficie-se para a destruição da contraprova das drogas e do objeto apreendido (fls. 09-10). Além disso, decreto a perda dos valores, em favor do Funad, eis que comprovadamente obtidos com a narcotraficância, nos termos dos arts. 63 e 72 da Lei n.º 11.343/2006.

P.I.C.

Paulo Antonio Canali Campanella – Juiz de Direito
(assinado eletronicamente)

Mauá, 20 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA